

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2012/11199

Acusada: Participações Morro Vermelho S.A.

Ementa: Suposto exercício abusivo do poder de controle em companhia aberta. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu **Absolver a companhia Participações Morro Vermelho S.A.** da imputação de prática de abuso de poder de controle, em suposta violação ao disposto no art. 117, §1º, alínea 'f', da Lei nº 6.404/76.

Proferiu defesa oral o advogado Marcelo Trindade, representante da companhia Participações Morro Vermelho S.A.

Presente a Procuradora Federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/11199

Acusada: Participações Morro Vermelho S.A.

Assunto: Apurar a responsabilidade da acionista controladora da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. pela prática de abuso de poder de controle (art. 117, §1º, alínea "f", da Lei nº 6.404/1976).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade da

Participações Morro Vermelho S.A. ("PMV"), na qualidade de controladora da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. ("CCDI", ou "Companhia"), pela prática de abuso de poder de controle, em infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea "f", da Lei nº 6.404/1976¹.

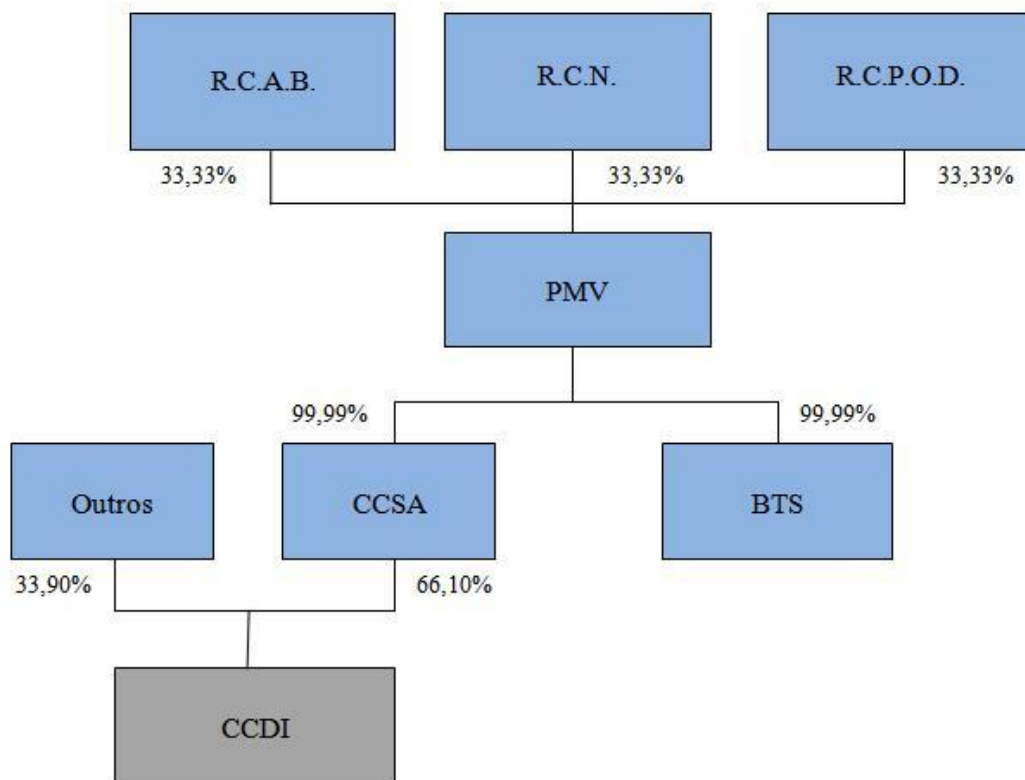
2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2011/8234, em que se analisou reclamação protocolada pelo acionista minoritário da CCDI J.A.L. ("Reclamante") junto à CVM, em 21.6.2011, a respeito de eventuais irregularidades na aquisição de parte do capital social da Projeto Rio Empreendimentos Ltda. ("Projeto Rio") pela BTS Participações e Investimentos Ltda. ("BTS"), sociedade controlada pela PMV.

II. DA ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

3. A CCDI é companhia aberta desde 29.1.2007, faz parte do Grupo Camargo Corrêa e tem como acionista controlador a Camargo Corrêa S.A. ("CCSA"), que detém 66,1% das ações representativas do capital social da Companhia.

4. A CCSA é controlada pela PMV, que, por sua vez, tem como principais acionistas três pessoas físicas (R.C.A.B., R.C.N. e R.C.P.O.D.). A BTS, sociedade utilizada para intermediar a operação de aquisição da parcela do capital social da Projeto Rio detida pela CCDI, tem 99,99% de seu capital social detido pela PMV.

5. A organização societária que relaciona as sociedades que participaram da aludida operação pode ser representada da seguinte forma:



III. DOS FATOS APURADOS PELA SEP

6. De acordo com a manifestação apresentada pela CCDI, essa Companhia era proprietária de metade das quotas de emissão da sociedade de propósito específico Projeto Rio, sendo que a outra metade era detida pela TST Rio *Development LLC* ("TST"). A Projeto Rio, por sua vez, era proprietária de 80,8% do terreno no qual seriam erguidas as duas torres do Empreendimento Ventura *Corporate Towers* ("Empreendimento Ventura").

7. O Empreendimento Ventura encontrava-se parcialmente concluído em 2008, quando, tendo em vista a venda da primeira torre, a CCDI passou a buscar formas de alienar a segunda torre ("Torre II").

8. Entre março e maio desse ano, a Companhia iniciou negociações com a The *Lighthouse Group*, que representava potencial investidor não identificado. No entanto, as tratativas não foram adiante.

9. Em julho de 2008, a CCDI contratou o Banco *Merril Lynch* de Investimentos S.A. ("Merril Lynch") para, na qualidade de assessor financeiro, coordenar a venda de forma estruturada, buscando potenciais compradores e auxiliando na negociação e execução da alienação (fls. 378 a 384). Contudo, em 1.7.2009, o contrato com a Merrill Lynch foi rescindido, uma vez que, apesar de o banco ter apresentado a oportunidade de aquisição da Torre II a 26 potenciais investidores², não foram obtidos os resultados esperados (fl. 386).

10. A administração da CCDI passou, então, a buscar, diretamente, potenciais adquirentes para a Torre II, o que resultou no recebimento de propostas das seguintes interessadas: (i) *Cyrela Commercial Properties* S.A. ("Cyrela"); (ii) Primaz Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Primaz"), representando interesses de investidores não identificados; (iii) REX Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("REX"); e (iv) PMV³.

11. A primeira proposta, não vinculante, foi apresentada pela Cyrela em 19.6.2009, que demonstrou interesse em adquirir determinados pavimentos da Torre II (equivalentes a 41.926,82 m²) e lojas no térreo do edifício (equivalentes a 1.088,76 m²) ao preço total de R\$ 395.000.000,00. Tal proposta estava, contudo, condicionada à realização de *due diligence*.

12. A Primaz, por sua vez, apresentou oferta em 23.6.2009 (fls. 1.069-1.071). A sociedade representava grupo de investidores de Minas Gerais não identificados e ofereceu, pela aquisição de toda a área locável da Torre II, o valor de R\$481.000.000,00. Esse montante corresponde ao preço de R\$12.000,00/m², sendo que 38% do valor da aquisição seria devido após a entrega do imóvel e a obtenção do habite-se. Em caso de sucesso da proposta, a CCDI deveria pagar à Primaz uma comissão equivalente a 3% do valor da venda pela prestação de serviços e intermediação imobiliária.

13. Além disso, nos termos da proposta, a concretização do pagamento estava condicionada à realização de *due diligence*, à aprovação por parte de comitê de investimentos e à presença de termos e condições satisfatórios na escritura de compra e venda. A proposta era condicionada, ainda, à assinatura de contrato de locação com determinadas condições⁴.

14. Contudo, devido ao fato de a Primaz não ter formalizado quem seriam os investidores interessados, essa proposta não foi adiante.

15. Em 2.12.2009, a Cyrela apresentou Carta de Intenções (fls. 390-393) por meio da qual reformulou proposta apresentada anteriormente. Em relação ao pagamento, a Cyrela propôs o valor total de R\$358.000.000,00, dividido da seguinte forma: (i) sinal de R\$100.000.000,00, dividido em cinco parcelas iguais; e (ii) R\$258.000.000,00, "*pagos em junho de 2010 contra o Auto de Conclusão (Habite-se)*" (fl. 391). O valor ainda poderia ser complementado em, no máximo, R\$125.000.000,00, caso a CCDI providenciasse a assinatura de contrato de locação do imóvel a ser adquirido⁵, o que totalizaria uma oferta de R\$483.000.000,00.

16. Essa proposta não previa o pagamento, por parte da Companhia, de comissão pela intermediação do negócio, mas foi condicionada à realização de *due diligence* "*que satisfizesse os critérios da [Cyrela] e de seus sócios estrangeiros,*" bem como à aprovação dos sócios estrangeiros e do Conselho de Administração dessa companhia. A CCDI, em manifestação datada de 11.10.2011 (fls. 295-342), afirmou que, considerando a área privativa de 40.120 m², o valor que lhe caberia seria de R\$225,25 milhões.

17. No dia seguinte à apresentação da proposta da Cyrela, 3.12.2009, a Primaz apresentou nova proposta. Nessa ocasião, a proponente ofereceu R\$476.000.000,00

por uma área locável de 43.330 m². O pagamento seria devido da seguinte forma: (i) 90% no ato da celebração de promessa de compra e venda do imóvel; (ii) 4% em 1.2.2010; e (iii) 6% em até três dias úteis, contados da data da expedição do habite-se. A esse respeito, a Companhia observou que, "*considerando a área privativa de 40.120 m² (e não de 43.330 m²), o valor seria de R\$440,74 milhões, resultando em R\$217,06 milhões para a CCDI*" (fl. 319).

18. A proposta condicionava o pagamento a determinados elementos, como a realização de *due diligence*⁶, e previa comissão a ser devida à Primaz, correspondente a 1,5% do valor da venda.

19. No dia 16.12.2009, a PMV apresentou sua proposta. Diferentemente das demais proponentes, esta sociedade desejava adquirir a totalidade das quotas da Projeto Rio detidas pela CCDI pelo valor de R\$207.000.000,00 (fls. 404-406). Além desse valor, a PMV comprometeu-se a realizar "*todos os aportes de capital necessários à finalização da obra da Torre II*" (fl. 404), no valor então estimado de R\$40.000.000,00⁷. Logo, o valor total dessa proposta correspondia a R\$247.000.000,00.

20. O pagamento seria assim realizado: (i) R\$100.000.000,00 devidos na data da assinatura dos documentos necessários à formalização da operação; (ii) R\$60.000.000,00 devidos em 30.4.2010; e (iii) R\$47.000.000,00 devidos em 5 dias úteis após a data de obtenção do habite-se e entrega do imóvel, o que ocorresse por último.

21. A proposta também informava que a aquisição poderia ser feita pela PMV ou por uma subsidiária sua (que viria a ser, mais tarde, a BTS)⁸. Além disso, como destacado pela CCDI em sua manifestação, não haveria a cobrança de comissão pela venda.

22. Por fim, em 17.12.2009, a REX apresentou proposta não vinculante no valor de R\$ 476.000.000,00 por toda a área locável pertencente à Projeto Rio. O documento mencionava, ainda, o pagamento de comissão de 1,5% à Primaz pelos serviços de intermediação imobiliária, tendo revelado que era a REX o investidor interessado por trás da proposta realizada por aquela sociedade em 3.12.2009.

23. Essa proposta não detalhou a forma de pagamento e, conforme destacado pela CCDI em sua manifestação, descontada a comissão devida à Primaz, restaria o valor de R\$469.000.000,00, dos quais R\$234.500.000,00 seriam destinados à Companhia.

24. Diante das propostas recebidas, a administração da CCDI contratou a Amaral D'Ávila Engenharia de Avaliações S/C Ltda. ("Amaral D'Ávila") para avaliar o valor econômico da Projeto Rio. O respectivo laudo, datado de 22.12.2009, avaliou a sociedade em R\$400 milhões, montante compreendido entre o intervalo de R\$385 milhões e R\$445 milhões, valores atribuídos à sociedade se assumidos cenários realista e otimista, respectivamente ("Laudo de Avaliação," fls. 65-184).

25. Também no dia 22.12.2009, a proposta da PMV foi apresentada ao Conselho de Administração da CCDI, juntamente com o Laudo de Avaliação. Assim, em reunião ocorrida nessa data, o Conselho de Administração, por unanimidade, (i) ratificou a

escolha e a contratação do avaliador; e (ii) autorizou a alienação à PMV da participação de 50% na Projeto Rio detida pela Companhia.

26. A operação foi celebrada no dia seguinte à reunião, em 23.12.2009, pelo valor de R\$247.000.000,00⁹, em linha com a proposta apresentada pela PMV, sendo que R\$211.000.000,00 foram recebidos diretamente pela CCDI e os R\$36.000.000,00 restantes representavam a estimativa de quanto a PMV ainda precisaria aportar para concluir a Torre II¹⁰.

27. Em 12.8.2010, cerca de oito meses após a operação, a BR *Properties* S.A ("BR *Properties*") adquiriu da Projeto Rio a Torre II pelo valor de R\$ 680.000.000,00. Cabe ressaltar que, à época, as obras da torre já haviam sido concluídas e 50% de suas lajes encontravam-se alugadas (fl. 322).

28. Em 21.6.2011, o Reclamante encaminhou manifestação à CVM (fls. 1 a 29), apontando eventuais irregularidades nas transações imobiliárias envolvendo partes relacionadas ao Grupo Camargo Corrêa. Segundo ele, haveria indícios de que as negociações foram realizadas sem considerar os interesses da CCDI e em benefício de seus acionistas controladores.

29. Com relação à alienação da participação societária na Projeto Rio, em síntese, o Reclamante questionou o valor então pago. Destacou, considerando que a mensuração do valor da Projeto Rio pelo Laudo de Avaliação teria se baseado nas perspectivas de projeções de caixa decorrentes da Torre II, o fato de que, apenas oito meses após a realização da operação, a Torre II foi negociada por um valor muito superior àquele atribuído à sociedade pelo Laudo de Avaliação.

30. Segundo entendimento do Reclamante, essa diferença nos valores atribuídos por ocasião da operação e no momento da alienação da Torre II à BR *Properties* indicaria que *"o laudo de avaliação apresentado para mensurar o valor da Projeto Rio pode[ria] conter irregularidades que certamente o macula[ria]m"* (fl. 07).

31. Em resposta a solicitação da SEP¹¹, protocolada em 11.10.2011 (fls. 295-341), a CCDI afirmou que a alienação da sua participação na Projeto Rio teria observado condições estritamente comutativas, uma vez que o valor da operação adequar-se-ia ao Laudo de Avaliação, bem como às propostas apresentadas por terceiros. Acrescentou também que o referido laudo *"foi elaborado de acordo com as melhores normas técnicas estabelecidas e a empresa escolhida pela Administração, Amaral D'Ávila Engenharia de Avaliações S/C Ltda., é uma das mais respeitadas no mercado e com ampla experiência ao longo dos últimos 20 anos"* (fl. 317).

32. Ademais, quanto às propostas apresentadas por terceiros, a Companhia afirmou que, por estarem condicionadas à aquisição de 100% da participação na Projeto Rio, estariam fadadas ao insucesso, uma vez que a TST havia se manifestado no sentido de que não teria interesse em alienar suas quotas. Além disso, a quantia oferecida incluía o valor relativo ao prêmio de controle e a operação dependia da aceitação da TST.

33. No que concerne à alienação da Torre II à BR *Properties* em um segundo momento, a CCDI argumentou que a transação foi decidida unilateralmente pela TST, que detinha, por conta de acordo de quotistas, o direito de determinar que a PMV

também vendesse suas quotas. Dessa forma, a transação não teria sido determinada por uma parte relacionada à CCDI.

34. Instada a manifestar-se sobre a contratação do Laudo de Avaliação¹², a Amaral D'Ávila afirmou¹³ que sua contratação foi formalizada em 18.12.2009 e que foram prestados esclarecimentos prévios a determinado administrador da CCDI acerca das premissas utilizadas na elaboração do laudo. A Amaral D'Ávila ainda ressaltou que atuou com total independência na avaliação da Projeto Rio e esclareceu que, embora não tivesse elementos que comprovassem esta alegação, era possível que os seus serviços tenham sido iniciados alguns dias antes da formalização da sua contratação.

35. A área técnica solicitou¹⁴ ainda a manifestação das demais sociedades que encaminharam propostas referentes à aquisição da Torre II sobre os seguintes pontos: (i) se teriam conhecimento da existência de outros interessados em adquirir o imóvel, inclusive a acionista controladora da CCDI; (ii) se foram informados sobre a elaboração de Laudo de Avaliação envolvendo o imóvel e a Projeto Rio; (iii) se foi apresentada contraproposta ou se lhes foi concedida a oportunidade de formular nova proposta; e (iv) se foram informados de que a CCDI ou a TST eventualmente não teriam interesse em alienar sua participação no imóvel. A Primaz e a REX foram questionadas ainda se o montante de R\$ 476 milhões, citado como valor de referência para aquisição do imóvel, foi sugerido pelos potenciais alienantes ou pelas próprias sociedades.

36. Em resposta, Cyrela, Primaz e REX apresentaram manifestações¹⁵ no sentido que (i) desconheciam as sociedades que participavam da concorrência para aquisição da Torre II; (ii) não tiveram acesso ao Laudo de Avaliação ou a qualquer informação adicional acerca da Torre II; (iii) não receberam contraproposta da CCDI ou tiveram a oportunidade de apresentar nova proposta; e (iv) não tinham conhecimento de que uma das quotistas da Projeto Rio poderia não ter interesse em alienar a sua participação no empreendimento.

37. Ademais, a Primaz esclareceu que, nas tratativas direcionadas à aquisição do imóvel, atuou a pedido de um de seus clientes com vistas a realizar operação de intermediação imobiliária. Informou também que os valores constantes da proposta encaminhada à CCDI em 3.12.2009 foram sugeridos pelos alienantes a fim de dar início às negociações.

38. Primaz e REX acrescentaram, ainda, que foram informadas que estaria à venda a totalidade da participação detida pela Projeto Rio na Torre II, não tendo sido discutida a possibilidade de alienação parcial.

39. Em 30.5.2012, a SEP encaminhou ofício¹⁶ à PMV, à BTS e aos administradores da CCDI que participaram da operação com algumas considerações a respeito dos fatos já apurados. A área técnica apontou que, a despeito dos demais interessados em adquirir a Torre II não terem conhecimento da participação da PMV nas tratativas, esta, por outro lado, não apenas conhecia os demais proponentes como também o conteúdo de suas propostas.

40. Isso porque, segundo a SEP, a PMV era o veículo por meio do qual a família Camargo Corrêa exercia o controle na Companhia. Ademais, à época da operação, a administração da CCDI contava com membros ligados à aludida família, o que

reforçaria a suspeita de que a PMV teve acesso privilegiado ao conteúdo das propostas.

41. A SEP destacou que não há como afirmar taxativamente que a proposta da PMV apresentava o maior valor que a CCDI poderia obter da alienação da Torre II, uma vez que as propostas formuladas pelos demais interessados eram preliminares e dependiam de tratativas subsequentes, que não chegaram a se desenvolver.

42. No que diz respeito ao benefício auferido pela PMV com a realização da operação, a área técnica apresentou cálculo a partir do qual, em tese, seria possível afirmar que eventual favorecimento à PMV alcançaria o valor de R\$ 86,5 milhões¹⁷.

43. Por fim, chamou atenção para o fato de o Laudo de Avaliação apresentar a mesma data da reunião do Conselho de Administração da CCDI que ratificou a contratação da Amaral D'Ávila e aprovou a alienação da participação societária na Projeto Rio, o que representaria indício de que os administradores tiveram acesso ao laudo antes de sua conclusão. Diante da relação de controle mencionada, seria possível concluir, segundo entendimento da SEP, que a PMV também tinha ciência do conteúdo do Laudo, o que representaria o esvaziamento do poder de barganha da CCDI na negociação e o favorecimento da PMV, única proponente a ter acesso ao documento.

44. Em resposta às considerações da SEP, apresentada em 27.6.2012 (fls. 1025-1028), PMV e BTS alegaram que tinham conhecimento da existência de outros interessados na Torre II, mas desconheciam a sua identidade ou o conteúdo de suas propostas.

45. PMV e BTS esclareceram que o veículo por meio do qual a família Camargo Corrêa exerceria o controle operacional sobre as empresas do Grupo seria a CCSA, e não a PMV. Afirmaram que não tiveram acesso ao Laudo de Avaliação ou ao seu conteúdo em nenhum momento. Também pontuaram que não possuíam conhecimento a respeito da forma como a administração da CCDI tratou as negociações com os demais interessados.

46. Ademais, manifestaram sua discordância diante do cálculo apresentado pela área técnica referente ao suposto favorecimento à PMV na negociação com a CCDI. Segundo a PMV e a BTS, o cálculo não teria levado em consideração fatores fundamentais para a determinação do preço de ativos imobiliários comerciais de alto padrão, o que implicaria em uma avaliação equivocada do valor da operação.

47. Ainda no que concerne ao montante pago pela PMV, acrescentaram que a TST teria demonstrado interesse em alienar a sua participação na Projeto Rio somente nas mesmas condições e pelo mesmo preço ofertados à CCDI. Isso indicaria que a transação foi realizada a valor de mercado.

48. Por fim, em 10.7.2012, a CCDI apresentou manifestação complementar (fls. 1029-1063) acerca das indicações preliminares apontadas pela área técnica por meio dos ofícios encaminhados aos administradores da Companhia.

49. A CCDI reafirmou a comutatividade da negociação celebrada com a PMV e a importância de realizar a operação ainda em 2009 para assegurar a continuidade de

suas atividades sociais. No que concerne à posterior alienação da Torre II à BR Properties, a Companhia acrescentou que, incluindo no valor final da operação o montante de R\$ 10.600.000,00 pago pela PMV em março de 2012, a variação entre os valores recebidos pela CCDI e pela PMV com a venda da participação na Projeto Rio seria de 29%, percentual muito inferior àquele apontado inicialmente pelo Reclamante.

50. Segundo a Companhia, *"tal variação (...) decorreu de fatores como 'momento de mercado', e o fato da alienação à BR Properties ter sido realizada após a conclusão das obras do Ventura 2"* (fl. 1045).

51. A manifestação acrescentou, ainda, que a TST teria manifestado interesse em vender sua participação à PMV pelo mesmo preço e nas mesmas condições em que a CCDI o fez. Essa informação legitimaria o preço da transação e foi corroborada pela própria TST em correspondência datada de 21.5.2012, segundo a qual a sociedade *"fez contatos com dirigentes da PMV e lhes indagou sobre o interesse da PMV em adquirir também - e pelo mesmo preço pago à CCDI - a sua participação no empreendimento Ventura, pois por aquele preço havia interesse da [TST] de vendê-la à BTS, controlada da PMV"* (fl. 1076).

IV. DA ACUSAÇÃO

52. Diante dos fatos acima apurados, a SEP apresentou, em 19.9.2012, termo de acusação (fls. 1139-1165) em face da PMV por, na qualidade de acionista controladora da CCDI e por meio de sua também controlada BTS, ter contratado com a Companhia em condições não equitativas. Nesse sentido, a área técnica destacou que a acionista controladora foi favorecida no processo de negociação e contratação com a CCDI, tendo em vista que contou com privilégios não concedidos a terceiros.

53. Segundo a SEP, pesaria a favor da acusada o envolvimento de terceiros na negociação e a declaração da TST no sentido de que estava disposta a alienar, à PMV, sua participação na Projeto Rio tal como fez a CCDI. A área técnica, contudo, relativizou o peso dessa manifestação, afirmando que *"a mera declaração da [TST], anos depois dos fatos e a pedido da CCDI, evidentemente não tem a mesma importância"* (fl. 1150).

54. Por outro lado, a partir do momento em que a PMV sinalizou interesse na aquisição da participação da CCDI na Projeto Rio, as evidências de que a operação teria sido conduzida em condições equitativas se esvaem. Isso porque, em síntese, os demais proponentes não foram informados de que estavam concorrendo com a PMV nem tiveram a oportunidade de superar a oferta formulada por essa acionista.

55. No entendimento da SEP, em razão de sua posição como acionista controladora indireta da CCDI, a PMV possuía acesso privilegiado às informações relativas à operação, notadamente as propostas encaminhadas por terceiros e o Laudo de Avaliação, *"embora ela própria e os administradores da CCDI neguem tal fato"* (fl. 1151).

56. Nesse sentido, apontou que a PMV tem como sócios membros da família Camargo Corrêa e que outros membros dessa família, que receberam as propostas de terceiros, faziam parte da administração da CCDI, sendo *"forçoso concluir que a PMV*

conhecia tais propostas" (fl. 1152). A única forma de se chegar a conclusão diversa, segundo o termo de acusação, seria presumir que os acionistas da PMV não tenham repassado informações aos seus administradores, o que seria "*completamente irrealista*" (fl. 1152).

57. Para a acusação, o fato de a PMV conhecer as propostas dos demais interessados permitiria que ela oferecesse apenas o valor suficiente para superá-las, o qual não representaria necessariamente o maior valor que estaria disposta a pagar pela participação societária da CCDI na Projeto Rio caso estivesse diante de transação com terceiros independentes.

58. Ademais, como não foi concedida aos demais interessados a oportunidade de apresentar novas propostas que superassem a oferta formulada pela PMV, "*deve ser vista com desconfiança a alegação de que a proposta da PMV, por prever valor financeiro maior e envolver apenas as cotas da Projeto Rio, teria sido mais vantajosa. Não se sabe se algum dos demais concorrentes faria oferta semelhante*" (fl. 1153).

59. A SEP também afirmou que a situação financeira da Companhia, que exigia a venda da Torre II o quanto antes, não justificava o fechamento do negócio com a PMV, uma vez que a CCDI já tinha recebido ao menos duas propostas até 3.12.2009.

60. Quanto ao acesso ao Laudo de Avaliação, a área técnica destacou que o documento é datado de 22.12.2009, mesmo dia da reunião do Conselho de Administração que o aprovou. Assim, considerando a hipótese mais provável, em que os administradores já conheciam o conteúdo do laudo antes de ser formalmente concluído, seria razoável supor que, pelos já mencionados vínculos existentes entre os conselheiros da CCDI e a PMV, esta também conhecia tal conteúdo.

61. Segundo o entendimento da SEP, o acesso exclusivo às aludidas informações asseguraria à PMV posição privilegiada na contratação com a CCDI, esvaziando o poder de barganha desta última.

62. De acordo com o termo, também pesaria contra a adequação da representação da Companhia na negociação com sua controladora o fato de que a remuneração total recebida pela maior parte dos administradores da CCDI era advinda de outras sociedades controladas pela PMV, "*ou seja, de controladas da contraparte com quem deveriam estar negociando*" (fl. 1155).

63. No que concerne aos valores da operação, a acusação afirmou que, não obstante a responsabilização da acionista controladora não ter por fundamento central a diferença entre os valores atribuídos à Torre II no momento da operação e na posterior alienação à BR *Properties*, não significa que essa circunstância deva ser desconsiderada na avaliação da conduta da acusada.

64. A análise das condições da alienação da Torre II pela PMV, em conjunto com a TST, forneceria uma estimativa aproximada do potencial prejuízo à CCDI e representaria outro indício, ainda que acessório, a corroborar as conclusões quanto ao favorecimento da acionista controladora.

65. Dessa forma, a acusação apresentou as circunstâncias consideradas no cálculo do eventual benefício da acionista controladora na operação, a saber: (i) a

necessidade de ajuste à metade do valor de venda da Torre II à BR Properties, tendo em vista que a alienação da participação da CCDI envolveu apenas 50% das cotas de emissão da Projeto Rio; e (ii) a atualização do valor da venda do imóvel a terceiros, em razão do decurso de aproximadamente oito meses entre os dois negócios¹⁸.

66. Para a SEP, não seria necessário, no entanto, realizar ajustes em decorrência da diferença nos níveis de desenvolvimento da Torre II nas respectivas datas de celebração dos negócios, uma vez que *"o valor pelo qual as cotas de emissão da Projeto Rio foram alienadas baseou-se na projeção de fluxos de caixa que seriam gerados ao longo da exploração econômica do empreendimento, notadamente aqueles posteriores à sua conclusão"* (fl. 1160)¹⁹.

67. Com base nessas considerações preliminares, a SEP apontou que o valor do potencial benefício econômico auferido ilegalmente pela PMV, por intermédio da BTS, equivaleria a R\$ 69.238.161,87, se desconsiderado o alegado pagamento adicional de R\$ 10.600.000,00 que a PMV teria efetuado à CCDI em março de 2012²⁰.

68. No que concerne aos demais fatores que, de acordo com a acusada, teriam contribuído para a diferença nos valores dos dois negócios, a área técnica argumentou que, ainda que tais fatores se mostrem aptos a justificar a valorização da Torre II, quase sempre seria possível reconstruir, *ex post*, razões plausíveis para determinado negócio. No entanto, o problema seria determinar em que medida essas circunstâncias teriam influenciado a contratação.

69. Diante dessa dificuldade, a área técnica procurou avaliar o processo de negociação conduzido entre a CCDI e a PMV, tendo concluído que não foram tomados os cuidados necessários à proteção dos interesses da Companhia, uma vez que a PMV gozou de condições privilegiadas no âmbito da negociação.

70. Sendo assim, a PMV, na qualidade de acionista controladora da CCDI, foi acusada da prática de abuso de poder de controle, em infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea "f", da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual constitui abuso de poder *"contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse em condições de favorecimento ou não equitativas"*.

71. Os administradores da CCDI também foram acusados no âmbito deste processo sancionador. Nesse sentido, (i) J.A.D.O., A.C.R.D., V.S.H. e S.Z., na qualidade de membros do Conselho de Administração da CCDI, foram acusados de terem aprovado a celebração de contrato não comutativo entre a CCDI e sua controladora indireta, PMV, em infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976; (ii) C.P.O.D. e L.R.O.N., na qualidade de membros do Conselho de Administração da CCDI, foram acusados de terem participado de deliberações em relação às quais possuíam interesses conflitantes, em infração ao art. 156, *caput*, da Lei nº 6.404/1976; e (iii) M.T.B. e F.S.N., na qualidade de diretores da CCDI, foram acusados de terem representado a Companhia na celebração do contrato com a sua controladora indireta, PMV, sem observar a exigência legal de comutatividade da operação, em infração ao art. 245 da Lei nº 6.404/1976 (fl. 1703).

72. Em 3.12.2013, todos os administradores celebraram termo de compromisso com a CVM.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

73. Em 31.10.2012, a Procuradoria Federal Especializada – PFE²¹ junto à CVM, após análise do preenchimento dos requisitos formais arrolados no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008²², entendeu que os elementos apontados pela SEP não seriam suficientes para identificar a falta de comutatividade na alienação da participação societária da CCDI na Projeto Rio, necessária para configurar a materialidade do tipo previsto no art. 117, §1º, alínea “f” da Lei nº 6.404/1976.

74. Inicialmente, a PFE ressaltou que a análise de eventual falta de comutatividade em contratos de natureza privada deve ter natureza objetiva. Apontou também que, no caso concreto, verificou-se legítimo esforço na alienação da participação detida pela CCDI na Projeto Rio, o qual culminou na contratação do Merrill Lynch e na apresentação de quatro propostas, sendo três delas de concorrentes independentes, cujos valores eram muito próximos ao valor apontado pelo Laudo de Avaliação. Sobre a credibilidade do referido laudo, a PFE asseverou que não há nos autos elementos que possam colocá-lo sob suspeita.

75. No que diz respeito ao acesso da PMV a informações sobre a negociação da Torre II, a PFE argumentou que *“ainda que a PMV tivesse conhecimento privilegiado das tratativas, o fato é que o valor por ela proposto foi superior às ofertas apresentadas pelos concorrentes independentes”* (fl. 1176). Diante disso, não seria possível identificar prejuízo à Companhia nesse ponto.

76. Quanto à possibilidade dos demais interessados apresentarem contrapropostas à oferta da PMV, caso lhes fosse concedida a oportunidade de dar prosseguimento à negociação, a PFE afirmou que não haveria obrigatoriedade na observância de procedimentos licitatórios ou pregões por companhias abertas em operações privadas. Ademais, em negociações como a presente, que pressupõem investimento relevante, a PFE apontou que os concorrentes dificilmente apresentariam valores inferiores àqueles que estariam dispostos a pagar.

77. Nos termos de sua manifestação, *“usualmente são realizados estudos sérios e exaustivos para que sejam estabelecidos os limites concretos do investimento a ser proposto pelo interessado e, principalmente diante do fato de, no caso concreto, haver mais de um interessado, esses limites devem ser expostos na primeira oportunidade, sob pena de outro concorrente sair vencedor”* (fl. 1177). Enalteceu, ainda, que a suposição da SEP representa *“perigoso ingresso na seara das decisões negociais, providas de ampla discricionariedade, não cabendo à CVM substituir os administradores nas decisões dessa natureza”* (fl. 1177).

78. Por fim, acrescentou que o fato de a própria TST, parte independente, ter demonstrado interesse em alienar à PMV sua participação na Projeto Rio pelas mesmas condições concedidas à CCDI deve ser levado em consideração na análise da comutatividade da operação.

79. Nessa direção, a PFE considerou indevidas as suspeitas levantadas pela SEP quanto à credibilidade da declaração da TST que confirmaria a intenção de alienar sua participação na Projeto Rio. Segundo o entendimento da Procuradoria, sendo parte independente, a TST não teria interesse em apresentar fatos inverídicos em favor da PMV, sendo o ônus de provar a ilegitimidade do documento exclusivo da acusação.

80. Por todo o exposto, a PFE concluiu que o ingresso da PMV na negociação teria beneficiado a sua controlada CCDI, não havendo vedação absoluta à contratação entre partes relacionadas. Assim sendo, diante da inexistência de materialidade, a PFE sugeriu o arquivamento do presente processo.

VI. DA FORMULAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO.

81. A SEP, então, apresentou manifestação (fls. 1187-1206) a respeito dos argumentos apresentados pela PFE²³. Além de reiterar grande parte dos argumentos já apresentados no Termo de Acusação, a SEP esclareceu alguns pontos à luz da manifestação da PFE.

82. Nesse sentido, em resposta ao entendimento manifestado pela Procuradoria de que uma sociedade privada não estaria obrigada a instaurar procedimento licitatório para contratar ou mesmo conferir tratamento isonômico aos potenciais adquirentes, a área técnica afirmou que a acusação se justifica não por conta de eventual prejuízo aos interessados na Torre II, mas, sim, porque o tratamento conferido pelos administradores à PMV não teve a finalidade de obter o maior valor possível para a CCDI.

83. Ainda no que concerne à necessidade de realização de procedimento concorrencial, a área técnica argumentou que, em que pese a CCDI não estivesse obrigada a se submeter a procedimento licitatório, seus administradores deveriam buscar sempre a melhor oferta disponível, não podendo negar ou impedir o recebimento de propostas mais vantajosas à Companhia.

84. Em seguida, a SEP analisou o argumento da PFE de que a avaliação da comutatividade necessária para a configuração do tipo previsto no art. 117, §1º, alínea "f", da Lei nº 6.404/1976 deveria ter natureza objetiva. Conforme o entendimento da área técnica, com base nesse argumento, a PFE não poderia ter considerado o Laudo de Avaliação como elemento favorável a corroborar a legitimidade da operação.

85. Isso porque o laudo, além de conter a opinião pessoal de quem o elabora, seria influenciado pelo sujeito que o contrata. Neste caso, as pessoas que contrataram o laudo, forneceram informações para a sua elaboração e aprovaram sua versão final foram, em sua maioria, administradores ligados à PMV. Assim, apesar de tê-lo considerado regular, a SEP entendeu que o Laudo de Avaliação não contribuiria para a legitimação da alienação da participação acionária da CCDI na Projeto Rio à PMV.

86. A área técnica afirmou, em seguida, que os elementos objetivos que deveriam ser considerados para avaliar a comutatividade da operação seriam a relação familiar que liga alguns administradores da Companhia à acionista controladora e o fato de terceiros, que poderiam ter realizado o negócio em igualdade de condições, a saber, a TST, não o terem feito.

87. Quanto à proposta de venda que a TST teria feito à PMV, a SEP esclareceu, em síntese, que a sua credibilidade foi questionada em razão das próprias declarações apresentadas pela CCDI. Isso porque, em sua primeira manifestação, a Companhia apontou, como uma das vantagens da proposta da PMV – que incluía apenas a

participação da CCDI na Projeto Rio –, o desinteresse da TST em alienar, durante as obras, a sua metade no capital social da Projeto Rio, o que acarretaria o insucesso de todas as outras propostas.

88. Contudo, anos após os fatos, quando qualquer declaração não mais poderia vincular o respectivo declarante, e no que faria parte da estratégia de quem assessorava a CCDI no âmbito das investigações conduzidas pela área técnica²⁴, a TST apresentou declaração contraditória com aquela da CCDI, uma vez que afirmou ter tentado alienar sua participação na Projeto Rio à PMV nas mesmas condições do negócio realizado por esta com a Companhia e antes mesmo de as obras serem concluídas.

89. Na visão da SEP, assim, tudo isso põe em dúvida a credibilidade da declaração da TST trazida aos autos, razão pela qual também ela não deveria ser considerada para legitimar a operação em tela.

90. Por fim, no que diz respeito à alegação da PFE de que, em contratações como a presente, as propostas apresentadas costumam refletir estudos sérios e exaustivos acerca dos valores a serem pagos pelo proponente, a SEP ressaltou que os próprios interessados, quando oficiados pela CVM por ocasião do presente processo sancionador, informaram que as propostas apresentadas tinham caráter de manifestação de interesse e não de proposta final.

91. Diante disso, a área técnica concluiu que caso a CCDI tivesse dado continuidade às negociações, concedendo aos interessados a oportunidade de apresentar novas propostas diante da oferta formulada pela PMV, a Companhia poderia ter obtido valores superiores com a alienação da sua participação na Projeto Rio.

92. No que concerne à análise da comutatividade da operação, conforme apontado pela área técnica, a PFE reconheceu ampla discricionariedade dos administradores no âmbito de suas decisões negociais, as quais só poderiam ser questionadas com base em evidências objetivas apuradas pela CVM. Ainda assim, seria possível admitir que falhas no procedimento decisório poderiam apresentar implicações na comutatividade da negociação.

93. Neste sentido, a PFE procurou demonstrar que tais falhas não teriam ocorrido na negociação que antecedeu a alienação da participação da Companhia na Projeto Rio. Contudo, na visão da SEP, a linha de raciocínio adotada pela Procuradoria seria circular, uma vez que reconheceria na própria discricionariedade dos administradores o fundamento para atestar a ausência de falhas nos procedimentos adotados na negociação. Se aceita a argumentação proposta pela PFE, as transações com partes relacionadas *“seriam revistas por padrões essencialmente iguais aos aplicáveis a decisões usuais de gestão”* (fl. 1198).

94. De acordo com a SEP, a ampla discricionariedade dos administradores só poderia ser reconhecida quando atendidos os pressupostos da regra de proteção à decisão empresarial, quais sejam, o caráter informado, refletido e desinteressado da decisão negocial. A observância desses pressupostos deveria ser verificada por meio da análise do processo de tomada de decisão.

95. Quanto às circunstâncias fáticas do caso em questão, apontou que, não obstante a importância da operação para a CCDI e o fato de se tratar de negociação com parte relacionada, a administração da Companhia não teria buscado a aprovação ou a ratificação da contratação pelos acionistas não controladores. *"Portanto, (...) nem há espaço para discutir se os acionistas tomaram uma decisão informada; aqui, essa decisão coube apenas aos próprios administradores"* (fl. 1202).

96. No que diz respeito ao interesse dos administradores na operação, ressaltou que, dos seis conselheiros da CCDI que deliberaram sobre a alienação da participação acionária na Projeto Rio, cinco tinham entre 70% e 90% de suas remunerações advindas de outras sociedades controladas pela PMV.

97. Ademais, a SEP apontou que a Amaral D'Ávila teve apenas dois dias úteis – de 18.12.2009, data da formalização de sua contratação, até 22.12.2009, ocasião da reunião do Conselho de Administração que aprovou o Laudo de Avaliação – para avaliar a Torre II e a Projeto Rio. Ainda que se admitisse, conforme alegado pelo avaliador, que os trabalhos teriam se iniciado alguns dias antes da contratação, a situação não seria muito diferente.

98. Por fim, concluiu que os critérios da política regulatória adotada pela SEP não representariam inovação no posicionamento da CVM. Pelo contrário, estariam em linha com os precedentes²⁵ desta autarquia, segundo os quais transações entre parte relacionadas devem ser avaliadas a partir do processo decisório que determinou os valores da operação.

VII. DA DEFESA

99. A PMV apresentou sua defesa em 1.4.2013, nos termos a seguir sintetizados (fls. 1514-1562).

100. A acusada, de início, alegou que a SEP ignorou as razões que tornavam a negociação da Torre II *"premente quanto à oportunidade, vantajosa quanto à substância e adequada quanto à forma,"* bem como o fato de que *"a PMV apresentou a melhor proposta de compra, sob qualquer ponto de vista"* (fl. 1515).

101. Após descrever o processo de negociação e as propostas recebidas, a defesa argumentou que a PMV *"oferecia as melhores condições financeiras, considerando o valor por metro quadrado, a ausência de comissão a intermediários, a forma de pagamento e a inexistência de condicionantes para o pagamento."* (fl. 1.525). Além disso, as negociações com os demais potenciais compradores envolveriam necessariamente a parte detida pela TST na Projeto Rio, uma vez que suas propostas incluíam toda a Torre II, à exceção da parcela de titularidade da UFRJ.

102. Ademais, por ser controladora indireta da CCDI, a PMV poderia adquirir a participação da Companhia na Projeto Rio sem a necessidade de anuência da TST. Isso porque, nos termos do contrato social e do acordo de quotistas da Projeto Rio, qualquer dos sócios desta sociedade poderia transferir, total ou parcialmente, sua participação a uma pessoa ligada, referida pela defesa como *"qualquer outra entidade que a controlasse, fosse por ela controlada ou estivesse sob controle comum, direto ou indireto"* (fl. 1525).

103. Em seguida, a defesa ressaltou que as condições do negócio não suscitaram qualquer estranheza, não tendo nenhum acionista minoritário se insurgido contra a alienação, e que as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2009 foram aprovadas em assembleia pela unanimidade dos votos.

104. Para a acusada, a comutatividade da operação restaria comprovada principalmente pelo interesse posteriormente demonstrado pela TST em alienar sua participação na Projeto Rio pelo mesmo preço e nas mesmas condições pelas quais a CCDI o fez, conforme declaração da própria TST acostada aos autos.

105. Acrescentou ainda que, posteriormente à realização da alienação, a TST negociou com a PMV, nova sócia na Projeto Rio, modificações nas condições do acordo de quotistas vigente, estipulando, entre outras determinações, a concessão, à TST, de *drag along* no caso de a PMV alienar a sua participação a terceiros. Segundo a PMV, essas alterações *"decorreram exatamente do fato de a CCDI ter alienado o ativo por um preço considerado atrativo pela [TST], sem que a [TST] tivesse participado da oportunidade"* (fl. 1527).

106. Assim, a despeito da crise financeira iniciada em 2008 e da retração do mercado imobiliário, a alienação da participação na Projeto Rio teria permitido à CCDI uma margem bruta de 46,5% do investimento feito na Torre II, *"em condições tão boas que sua sócia, um dos maiores grupos mundiais no setor, quisesse imediatamente alienar sua fração nas mesmas condições"* (fl. 1528).

107. Em relação à venda, oito meses depois, da Torre II à BR *Properties*, a defesa pontuou que o mercado brasileiro experimentou transformações positivas. Nesse sentido, destacou que o Ibovespa recuou 11,16% no primeiro semestre de 2010, tendo valorizado 13,18% nos seis meses que se seguiram. Seria esse o contexto, portanto, no qual a BR *Properties* adquiriu, em 12.8.2010, a Torre II pelo valor de R\$680.000.000,00.

108. Ainda segundo a acusada, a operação foi diretamente conduzida pela TST e resultou no *"maior negócio imobiliário do Brasil até então, em aporte direto"* (fl. 1.529), com amplo destaque na imprensa em relação ao valor obtido por PMV e TST.

109. Em seguida, a defesa passou a tratar dos privilégios que a PMV teria supostamente obtido na contratação com a CCDI: o acesso (i) às ofertas dos demais interessados e (ii) ao Laudo de Avaliação.

110. Sobre o primeiro privilégio, argumentou, inicialmente, que não há, nos autos, qualquer evidência de que a PMV conhecia as propostas dos outros concorrentes, *"tratando-se de uma presunção frágil e contraditória com os demais elementos apurados pela própria SEP"* (fl. 1532).

111. Contudo, ainda que se assumisse a premissa de que a acusada teve acesso a essas informações, isso não explicaria porque todas as propostas foram superadas pela sua oferta e porque a TST, *"qualificadíssima sócia da CCDI"* (fl. 1532), quis vender o imóvel pelo mesmo preço. Destacou a defesa, nesse sentido, que *"a PMV pagou o maior preço, nas melhores condições, e esse preço superou as melhores ofertas que a CCDI conseguiu obter depois de quase dois anos de esforço de venda, no Brasil e no exterior"* (fl. 1532).

112. Enquanto as outras propostas referiam-se a valores na casa dos R\$ 11.000,00/m², visavam à aquisição de toda a área locável que cabia à Projeto Rio na Torre II e condicionavam o pagamento de uma parcela do preço à locação das lajes ou à conclusão das obras, a proposta da PMV oferecia à Companhia o pagamento de parcela substancial à vista, não o condicionava à concessão do habite-se, à locação do imóvel ou a qualquer outro evento. Além disso, sua proposta era a única direcionada à aquisição de 50% da Projeto Rio.

113. A defesa acrescentou, ainda, que as demais propostas foram formuladas no pressuposto da aquisição do controle isolado da sociedade, o que acarretaria necessariamente o pagamento de um prêmio de controle completo da sociedade ou do ativo. Além disso, observou que os compradores potenciais, antes do fechamento da transação, realizariam auditorias, que, se viessem a alterar o preço inicialmente ofertado, só poderiam reduzi-lo, e nunca aumentá-lo.

114. Dessa forma, *"ao aceitar a proposta da PMV, [a CCDI] não apenas obteve o melhor preço como apropriou-se do prêmio de controle sem a necessidade de negociar com [a] co-controlador[a] [TST]. E ainda deixou de correr os riscos inerentes à due diligence"* (fl. 1533).

115. Ademais, conforme apontado pela acusada, a suposição de que a PMV teria conhecimento das demais propostas não estaria amparada em qualquer elemento concreto, fundando-se somente na relação de controle que a ligaria à Companhia. Nessa linha, argumentou que os diretores da CCDI reportavam o andamento das negociações aos membros do Conselho de Administração, *"mas não necessariamente informando todos os elementos de cada proposta recebida (...)"* (fl. 1534).

116. De qualquer forma, a PMV afirmou ser essa ponderação inútil, visto que a sua proposta foi a maior e envolveu as melhores condições.

117. No que diz respeito ao suposto conhecimento do Laudo de Avaliação, a acusada contestou as premissas nas quais se baseou a acusação para questionar o processo de negociação estabelecido entre a Companhia e a acusada.

118. Em primeiro lugar, ressaltou que a proposta da PMV foi apresentada em 16.12.2009, anteriormente à formalização da contratação da Amaral D'Ávila e à apresentação da conclusão do Laudo de Avaliação, nos dias 18.12.2009 e 22.12.2009, respectivamente. Dessa forma, ainda que a Amaral D'Ávila tenha iniciado os trabalhos alguns dias antes da formalização da contratação, *"sua opinião não estava formada, e muito menos as suas conclusões disponíveis, em 16 de dezembro, de modo que pudessem influenciar a apresentação da proposta da PMV"* (fl. 1535).

119. Não obstante, esse apontamento da acusação também seria irrelevante, pois a finalidade do Laudo de Avaliação teria sido a de verificar, com base em opinião técnica, aquilo que o mercado havia demonstrado com base nas propostas encaminhadas, que foram superadas pela oferta da PMV. Assim, não haveria condições de favorecimento a quem apresentou a melhor proposta.

120. Em segundo lugar, a acusada argumentou que o Laudo de Avaliação não teria a influência pretendida pela acusação no processo decisório da administração da CCDI,

uma vez que os administradores da Companhia acompanhavam a evolução dos preços praticados no mercado imobiliário, tendo, portanto, capacidade para decidir sobre a conveniência das propostas apresentadas pelos interessados na Torre II.

121. Isto posto, afirmou que o Laudo de Avaliação teria sido contratado pela CCDI como medida adicional de cautela, a fim de assegurar que os preços das propostas estavam dentro de um intervalo razoável, observando, inclusive, a postura recomendada pela doutrina no caso de contratação com parte relacionada²⁶.

122. Em seguida, a defesa voltou a mencionar a declaração da TST no sentido de que, se a acusada tivesse interesse, teria alienado sua participação na Projeto Rio para a PMV nas mesmas condições pelas quais a CCDI o fez. Caso assim tivesse ocorrido, a TST não teria vendido sua participação *"cerca de oito meses depois, com o ganho que, segundo a acusação, a PMV quis abocanhar"* (fl. 1538).

123. A acusada, então, citando entendimento da PFE exposto em sua manifestação, contestou a desconsideração da SEP acerca dessa declaração. Nesse sentido, reiterou que a TST, mesmo sem ter necessidade de realizar a venda da sua parte na Projeto Rio naquele momento, decidiu oferecê-la à PMV, o que comprovaria que o preço por esta pago foi muito satisfatório e substancialmente superior aos que foram oferecidos pelos demais interessados.

124. Posteriormente, a defesa explicou que a realização de um aumento de capital da CCDI para suprir com a necessidade de caixa por parte da Companhia, alternativamente à venda da participação na Projeto Rio, seria pior para os acionistas minoritários. Isso porque, considerando a desvalorização das incorporadoras desde a eclosão da crise em setembro de 2008, as ações a serem emitidas teriam valor baixo, acarretando expressiva diluição desses acionistas em prol do aumento de participação da PMV no capital social da Companhia²⁷.

125. A acusada passou a apresentar, então, os elementos ligados à CCDI que demonstrariam que a negociação conduzida junto à PMV era *"premente quanto à oportunidade, vantajosa quanto à substância e adequada quanto à forma"* (fl. 1541).

126. Quanto à oportunidade, destacou que a CCDI enfrentava significativas pressões de caixa durante o ano de 2009, de forma que, em dezembro daquele ano, além de alienar a sua participação na Projeto Rio, a Companhia também realizou uma emissão de debêntures que permitiu a recomposição integral de seu caixa.

127. Caso tais medidas não fossem adotadas pela administração da CCDI, havia o risco concreto de a Companhia ter que recorrer, no curto prazo, a outras fontes de captação para cumprir suas obrigações, entre elas o aporte de recursos para conclusão das obras da Torre II. A acusada ressaltou ainda que, por se tratar de empreendimento controlado em conjunto com a TST, a CCDI sequer poderia conduzir o andamento das obras de acordo com as suas possibilidades de desembolso, devendo seguir fielmente o cronograma previamente estabelecido.

128. Ainda no que concerne à oportunidade do negócio, a PMV alegou que a alienação da participação acionária na Projeto Rio permitiu à CCDI reverter o resultado do exercício. Nesse sentido, no lugar do prejuízo esperado de R\$40.000.000,00, a Companhia apresentou lucro líquido de R\$58.000.000,00. Ademais, para que a

Companhia pudesse deduzir integralmente o prejuízo acumulado do lucro a ser gerado com a operação, esta deveria ser realizada ainda em 2009.

129. Em seguida, no que concerne às condições da contratação, a acusada procurou demonstrar que eventual negociação com os demais interessados conduziria a uma diminuição nos valores ofertados inicialmente e não a um aumento.

130. Em primeiro lugar, destacou que as propostas estavam voltadas à aquisição de 100% das quotas da Projeto Rio. Logo, caso essas propostas fossem reformuladas para incluir apenas a participação da CCDI, os preços atribuídos à operação seriam reduzidos, em razão da ausência de prêmio de controle. Outro fator que poderia influenciar negativamente os preços ofertados seria a sujeição da operação à realização de *due diligence*.

131. Em segundo lugar, conforme apontado pela acusada, a SEP estaria equivocada ao considerar que a comunicação aos demais interessados a respeito da participação da PMV nas negociações poderia aumentar o valor das propostas. Pelo contrário, em regra, a possibilidade do exercício do direito de preferência por um dos negociantes reduziria o interesse de terceiros em participar do processo, uma vez que suas propostas poderiam sempre ser cobertas.

132. Por outro lado, se houvesse a perspectiva de obter lucros ainda maiores com a venda da participação na Projeto Rio a terceiros, a TST teria demonstrado o seu interesse, e não apresentado proposta à PMV de vender as suas quotas em iguais condições àquelas oferecidas à CCDI.

133. Mais adiante, a acusada ressaltou que *“as transações da companhia com sua controladora não são vedadas por lei. A proibição é de que, nestas transações, o acionista controlador seja de alguma forma beneficiado”* (fl. 1546). Assim, destacou, no presente caso, as vantagens, para a CCDI, de negociar com a sua controladora.

134. Dentre esses benefícios estaria a dispensa à realização de *due diligence*, uma vez que, na qualidade de acionista controladora, a PMV já estava exposta a todos os riscos relativos ao Empreendimento Ventura. Isso teria permitido a conclusão da operação ainda em 2009, de forma que a CCDI pôde aproveitar o benefício fiscal decorrente da alienação da sua participação na Projeto Rio.

135. Ademais, a alienação à PMV não dependia de qualquer autorização da TST, visto que, conforme estabelecido na cláusula 11.2 do acordo de quotistas (fls. 438-454), *“a CCDI poderia transferir a qualquer pessoa ligada sua participação na Projeto Rio, sem precisar da aquiescência da outra quotista”* (fls. 1.547-1.548).

136. Assim, caso a Companhia optasse por alienar a sua participação a um dos terceiros interessados, a conclusão do negócio dependeria não apenas da adequação da proposta para englobar apenas 50% das quotas da Projeto Rio, mas também da anuência da TST com o ingresso de terceiro na sociedade.

137. Quanto à opção feita pela CCDI para lidar com as suas necessidades de caixa, a acusada esclareceu que a estrutura mais usual de captação de recursos utilizada pelas incorporadoras, a saber, a oneração do próprio imóvel em construção, não estava disponível à Companhia.

138. Isso porque, sendo a Projeto Rio uma sociedade controlada em conjunto pela CCDI e pela TST, a utilização do imóvel como garantia para financiamento do empreendimento dependia da concordância de ambos os sócios. Contudo, *"o modelo de financiamento utilizado pela [TST] não contempla a oneração do empreendimento em construção. Ela normalmente capta no mercado, através do lançamento de fundos de investimento, os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto e financiamento das obras"* (fl. 1549).

139. Desse modo, privada de uma das formas mais tradicionais de captação de recursos, a CCDI teria recorrido a uma operação oportuna, vantajosa e adequada às suas necessidades de caixa.

140. Por fim, a PMV procurou demonstrar que a acusação teria se deixado influenciar pela diferença entre o preço pago pela PMV na aquisição da participação na Projeto Rio e o valor que veio a ser recebido posteriormente pela alienação feita à *BR Properties*. Esta diferença poderia ser explicada por eventos ocorridos após a celebração da operação e que não poderiam ser antevistos pelas partes envolvidas na negociação.

141. Nesse sentido, a acusada destacou que, no quarto trimestre de 2009, momento em que foi realizada a alienação da participação societária na Projeto Rio pela CCDI, o mercado imobiliário sofria com os efeitos da crise econômica mundial, apresentando *"absorção líquida negativa do mercado de escritórios, isto é, a demanda por novos espaços não [era] suficiente para suprir o aumento da oferta"* (fl. 1551).

142. Contudo, ao longo do ano de 2010, houve evidente melhora na situação do mercado imobiliário, com destaque para a recuperação do índice de absorção líquida de imóveis para escritórios na cidade do Rio de Janeiro.

143. Dessa forma, o mercado imobiliário de escritórios teria sofrido grande transformação entre o período em que foi celebrada a aquisição da participação na Projeto Rio pela PMV e a posterior alienação da Torre II à *BR Properties*, mostrando-se muito mais aquecido neste segundo momento, o que justificaria a diferença nos valores das duas operações.

144. Acrescentou que, entre dezembro de 2009 e agosto de 2010, as obras da Torre II foram integralmente concluídas, bem como mais de 50% de sua área útil encontrava-se locada a valores superiores àqueles praticados pelo mercado.

145. Concluiu, então, que os fatores apontados, como o risco econômico do empreendimento corrido pela PMV, explicariam perfeitamente o ganho auferido pela acusada com a posterior alienação da Torre II à *BR Properties*. Nesse sentido, o preço do negócio realizado pela PMV teria sofrido a mesma repercussão caso o resultado do investimento tivesse sido negativo, *"assim como um ganho maior, proporcional ao maior risco, teria se produzido no patrimônio da PMV caso ela houvesse adquirido a parcela da [TST] que lhe foi ofertada"* (fl. 1.555).

146. Em seguida, a acusada afirmou que o dano necessário para a caracterização do abuso de poder de controle não teria ocorrido na operação impugnada, não havendo qualquer favorecimento à PMV.

147. Segundo a acusada, *"a análise do favorecimento ou da ausência de condições equitativas na operação depende[ria] da comparação com outras operações semelhantes, ou mesmo a verificação de que um terceiro desinteressado faria a operação nas condições acordadas entre controlador e controlada"* (fl. 1.555)²⁸.

148. Nesse sentido, afirmou que a oferta apresentada pela PMV era superior às dos demais interessados e que a TST, terceiro independente, teria demonstrado a sua intenção de alienar a sua participação na Projeto Rio nas mesmas condições pelas quais a CCDI o fez. Além disso, a operação contou com a aprovação de todos os conselheiros da CCDI, inclusive o membro independente, o que reforçaria o entendimento de que a alienação à PMV, por intermédio da BTS, teria sido celebrada em condições equitativas.

149. Por fim, asseverou que a acusação teria ignorado todas as circunstâncias que corroborariam com a legitimidade da operação, imputando responsabilidade à PMV com base em conjecturas destituídas de prova, o que feriria o princípio da presunção de inocência, que se aplica aos processos administrativos sancionadores.

VIII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

150. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 13.6.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Ana Novaes em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ "Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. §1º - São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;"

² A lista dos potenciais investidores consultados encontra-se à fl. 1.067.

³ As propostas encontram-se às fls. 391 a 413.

⁴ Tais condições são: (i) valor mínimo de locação de R\$ 5.250.000,00 por mês; (ii) duração de 10 anos, prorrogável por igual período; (iii) empresa de primeira linha; e (iv) até o habite-se, utilização do INCC como indexador; após o habite-se, passará a ser utilizado o IGP-M ou Cesta de Índice.

⁵ De acordo com a proposta, para que o valor adicional fosse devido, o contrato de locação deveria ser assinado até o dia 30.9.2010, *"para empresas de primeira linha, com prazo de contrato de no mínimo 5 anos e com garantias de locação."*

⁶ Tais elementos são: *"a) Celebração da Promessa de Venda e Compra no prazo máximo de 30 dias, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, contados da data de aceitação dessa proposta, prorrogáveis por mais 30 dias, a critério do Vendedor; b) Afetação patrimonial da Incorporação Imobiliária do Empreendimento, exclusivamente no tocante às Unidades autônomas da Torre II, nos termos da Lei 10.931/2004, sob responsabilidade do Vendedor, a ser concluído no menor prazo possível; c) Resultado satisfatório de laudo ambiental, a ser conduzido por empresa independente a expensas do Comprador, no*

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de liberação do acesso ao imóvel e a documentação pertinente; e d) Resultado satisfatório de diligência sobre o Imóvel e o Vendedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega da documentação pertinente” (fl. 396).

⁷ Essa parcela do preço, segundo a proposta, poderia ser aumentada ou reduzida conforme o valor dos custos a serem incorridos com as obras necessárias.

⁸ Nestes termos, a alienação da participação acionária da CCDI na Projeto Rio foi formalizada na 52ª alteração do contrato social da Projeto Rio (fls. 416 a 436), na qual figurou como compradora e nova quotista da sociedade a BTS, subsidiária integral da PMV.

⁹ A CCDI informou que, em março de 2012, a PMV realizou novo pagamento no valor de R\$10,6 milhões em decorrência de cláusula de ajuste de preço prevista no contrato celebrado com a Companhia para a aquisição da sua participação na Projeto Rio (fl. 1034).

¹⁰ A SEP ressaltou que *“De acordo com o laudo, os valores estimados para finalização [da Torre II] eram de aproximadamente R\$ 120,5 milhões (fl. 87), o que explicava a maior parte da diferença entre o valor do empreendimento em si como se estivesse pronto (R\$ 524,4 milhões, no cenário realista) e o valor da Projeto Rio (R\$ 385 milhões nesse mesmo cenário).”* (nota de rodapé nº 7, fl. 1143).

¹¹ Ofício CVM/SEP/GEA-3/nº 93011, de 22.8.2011 (fls. 221 e 222).

¹² Ofícios CVM/SEP/GEA-3/nº 987/12, de 23.3.2012 e CVM/SEP/GEA-3/nº1004/12, de 30.3.2012 (fls. 834-835 e 840-841, respectivamente).

¹³ As manifestações da Amaral D’Ávila constam das fls. 837-838, 843-845 e 848-849.

¹⁴ Ofícios CVM/SEP/GEA-3/nº991/12, CVM/SEP/GEA-3/nº992/12 e CVM/SEP/GEA-3/nº993/12, de 26.3.2012 (fls. 850-851, 855-856 e 862-863, respectivamente).

¹⁵ As manifestações da Cyrela, da Primaz e da REX constam, respectivamente, das fls. 853-854, 860-861 e 866-867.

¹⁶ Ofícios CVM/SEP/GEA-3/nº 1148 à 1160/12 (fls. 930-1021).

¹⁷ O cálculo apresentado pela SEP consta da fl. 1016. A área técnica apontou que a diferença entre o valor da transação com terceiros e o valor do negócio celebrado com a PMV foi (i) ajustada para refletir o fato de que a CCDI detinha somente 50% das quotas de emissão da Projeto Rio; e (ii) trazida a valores da época, aplicando-se a mesma taxa de desconto de 11,48% ao ano assumida no laudo.

¹⁸ Conforme apontado pela SEP, haveria uma forma objetiva e disponível de realizar a atualização do valor de venda da Torre II: *“descontá-lo pelo custo de capital estimado no laudo elaborado pela Amaral D’Ávila, de 11,48% ao ano”* (fl. 1160).

¹⁹ A SEP ressaltou que, ainda que a CCDI tenha chamado atenção para o fato de que o risco dos fluxos de caixa durante a construção da Torre II era maior, tal fato já *“era conhecido quando da avaliação do Empreendimento Ventura pela Amaral D’Ávila e, desse modo, deve ter sido levado em conta na definição da taxa de desconto adotada, de 11,48% ao ano”* (fl. 1.160).

²⁰ A área técnica informou que não foi apresentada prova documental de que tal pagamento teria sido realizado.

²¹ Memo nº 98/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.1167-1185).

²² Art. 6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

²³ MEMO/CVM/SEP/GEA-3-nº368/12, de 4.12.2012.

²⁴ Nas palavras da manifestação da SEP: *“Com o desenrolar do processo administrativo na CVM, todavia, a CCDI, seus administradores e controladores passaram a receber reiterados pedidos de informação. Evidentemente muito bem assessoradas, tais pessoas puderam gradativamente perceber a interpretação da*

SEP sobre os fatos e notaram que era o interesse – e não o desinteresse – da [TST] que poderia ser usado em seu favor.

Eis então que, já depois da fase de intimação para os fins do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, a CCDI obtém junto à [TST] e faz chegar aos autos uma declaração que contradiz frontalmente o que ela, CCDI, havia afirmado antes” (fls. 1194-1195).

²⁵ Neste sentido, a SEP citou os PAS CVM nº RJ2005-1443, julgado em 10.05.2006; PAS nº 08/2005, julgado em 12.12.2007; e PAS CVM nº RJ2005/0097, julgado em 15.03.2007.

²⁶ A defesa citou o seguinte trecho: “É recomendável, para se prevenir o controlador de eventuais ações judiciais propostas por minoritários, que a deliberação do órgão competente que aprovar a contratação demonstre, se possível com estudos independentes, que estão sendo seguidas as condições de mercado” (Nelson Eizirik; Ariádna B. Gaal; Flávia Parente; Marcus de Freitas Henriques. *Mercado de Capitais: Regime Jurídico*. 3ª ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2011. p. 412).

²⁷ Em termos práticos, a defesa pontuou que “um aumento de capital da CCDI de R\$250 milhões, com a cotação média das ações no mês de dezembro de 2009 (R\$ 5,36), teria levado à emissão de mais de 46 milhões de ações, aumentando o capital social em mais de 40% (eram 113 milhões de ações então). Em um cenário, que era a regra naqueles tempos, em que os acionistas minoritários não subscrevessem o aumento de capital, isso teria feito a participação (indireta) da PMV no capital social da CCDI elevar-se substancialmente, à custa da diluição dos demais investidores” (fls. 1540-1541).

²⁸ Nessa direção, a PMV citou o seguinte trecho: “O direito societário tem buscado identificar alguns critérios para aferir a legitimidade do comportamento do controlador, tendo em vista a configuração do caráter comutativo das relações mantidas com a controlada. Há dois testes básicos para a aferição do comportamento equitativo do acionista controlador: (a) comparação da operação com outra, hipotética; (b) ou com outras similares, realizadas no mercado. Conforme o primeiro teste, denominado no direito norte-americano “arms-length bargain comparison”, a decisão não será considerada equitativa se o resultado da operação, para a companhia controlada, resultar menos vantajoso do que seria caso tivesse sido tomada por uma pessoa independente, sem qualquer conflito de interesses. De acordo com o segundo teste (o ‘fairness test’), a decisão será tida como ilegítima se o resultado da operação for menos vantajoso para a companhia do que o verificado em outras, realizadas no mercado por partes independentes. Tais testes são particularmente relevantes quando as companhias envolvidas têm administradores comuns (‘interlocking directors’), em tal situação é necessário examinar se os negócios seriam celebrados ainda que não houvesse qualquer relação entre as partes envolvidas. O acionista controlador e os administradores das companhias envolvidas devem considerar não apenas se o negócio será equitativo, mas também se a operação está atendendo aos melhores interesses das sociedades envolvidas. Assim, pode ficar caracterizada a responsabilidade do acionista controlador se ficar demonstrado que o negócio: (a) ocorreu fora dos padrões geralmente adotados no mercado em transações semelhantes; (b) não foi realizado de forma a atender aos melhores interesses da companhia; e (c) não teria sido concluído se as partes fossem independentes ou não interessadas” (Nelson Eizirik; Ariádna B. Gaal; Flávia Parente; Marcus de Freitas Henriques. *Mercado de Capitais: Regime Jurídico*. 3ª ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2011. Pág. 406-407).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/11199

Acusada: Participações Morro Vermelho S.A.

Assunto: Apurar a responsabilidade da controladora da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. pela prática de abuso de poder de controle (art. 117, §1º, alínea “f”, da Lei nº 6.404/1976).

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade de Participações Morro Vermelho S.A. (“PMV”), em razão de suposto exercício abusivo do poder de controle na companhia aberta Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“CCDI” ou “Companhia”), em infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea “f”, da Lei nº 6.404/1976.

2. O Termo de Acusação decorre da análise, realizada pela área técnica da CVM, acerca da transação por meio da qual a BTS Participações e Investimentos Ltda. (“BTS”), sociedade controlada pela PMV, adquiriu a participação da CCDI na Projeto Rio Empreendimentos Ltda. (“Projeto Rio”), a qual, por sua vez, era proprietária da segunda das duas torres do empreendimento denominado *Ventura Corporate Towers* (“Empreendimento Ventura”).

3. De acordo com a SEP, a PMV, valendo-se de sua condição de controladora, teria contratado com a Companhia em condições de favorecimento, cometendo, assim, a modalidade de abuso prevista no aludido art. 117, §1º, alínea “f”.

4. A SEP também entendeu que deveriam ser responsabilizados os administradores da Companhia que participaram do processo decisório que resultou na celebração do aludido negócio. Alguns teriam incorrido em conflito de interesses, vedado pelo art. 156 da Lei nº 6.404/1976, uma vez que teriam intervido na operação, não obstante os laços familiares que os ligavam aos controladores indiretos da Companhia. Outros não teriam observado o dever estabelecido no art. 245 da Lei, porquanto teriam deixado de adotar medidas destinadas a assegurar a equidade do negócio.

5. No entanto, todos os administradores que figuravam neste processo firmaram termo de compromisso com a autarquia, de modo que resta examinar neste julgamento a regularidade da conduta da controladora PMV à luz do já mencionado art. 117, §1º, alínea “f”.

6. De acordo com a SEP, verifica-se o abuso “*na medida em que na contratação com a CCDI a PMV teve privilégios que terceiros não tiveram*” (fls. 1.159). Como se depreende da leitura do termo de acusação, os privilégios seriam, em síntese, os seguintes:

- (i) a PMV tinha conhecimento das propostas que a administração da CCDI tinha recebido de terceiros, de modo que estava em condições de oferecer pelo ativo valor que bastasse para superar as demais propostas;
- (ii) os terceiros interessados na aquisição do ativo não sabiam que a PMV também estava concorrendo e tampouco tiveram a oportunidade de superar a proposta formulada por esta última; e
- (iii) diferentemente dos demais interessados, a PMV teve acesso ao laudo de avaliação do ativo encomendado pela administração da Companhia.

7. Como se vê, a acusação não se baseia na suposta falta de proporcionalidade entre as prestações que couberam a cada parte do contrato. Sustenta-se, em vez disso, no exame do processo de negociação que antecedeu à operação, o qual, em sua opinião, foi conduzido de maneira enviesada com vistas a favorecer a PMV.

8. A prevalecer a interpretação levada a cabo pela área técnica, as *"condições de favorecimento, ou, não equitativas"*, a que alude o disposto no art. 117, §1º, alínea "f", diriam respeito ao processo de contratação, e não ao contrato propriamente dito.

9. No entanto, este Colegiado, em mais de uma oportunidade, entendeu que a referida modalidade de abuso de poder de controle se configura mediante a prova de que a transação foi lesiva para a companhia aberta, seja porque não foi efetuada de maneira a atender aos seus melhores interesses, seja porque foi realizada em condições desequilibradas que favoreceram o controlador¹.

10. Do mesmo modo, nos autos deste processo, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ressaltou que *"o que se veda é a não comutatividade nessas contratações"* (fl. 1.278).

11. A meu ver, essa é a interpretação correta do preceito previsto no art. 117, §1º, alínea "f", como se depreende da leitura sistemática dos demais dispositivos da Lei nº 6.404/1976 que tratam, igualmente, das *condições de contratação* entre a companhia e partes relacionadas.

12. Cumpre mencionar, nessa direção, o já citado art. 245 que exige dos administradores que cuidem para que as operações com sociedades do mesmo grupo econômico observem *"condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado"*. Nesse mesmo diapasão, o parágrafo primeiro do art. 156 estabelece que *"o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros"*.

13. As diversas expressões empregadas – tais como *"condições estritamente comutativas"*, *"pagamento compensatório"* e *"condições idênticas às que prevalecem no mercado"* – evidenciam que tais dispositivos têm em vista o conteúdo do ajuste contratual. E, a meu ver, não haveria razão para de outro modo interpretar-se o disposto no art. 117, §1º, alínea "f". Ao menos por coerência, cumpre identificar as *"condições de favorecimento, ou, não equitativas"*, a que alude o dispositivo, no negócio jurídico, e não no processo decisório que o precedeu.

14. Neste tocante, o que se verifica é que a Lei nº 6.404/1976 submeteu administradores e controladores a responsabilidades distintas no que diz respeito à realização de operações entre a companhia e sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.

15. De uma parte, em atenção ao disposto no art. 245, cumpre aos administradores zelar para que essas transações sejam equitativas. Ou seja, devem agir com especial diligência, adotando, durante o processo decisório, medidas aptas a resguardar os interesses da companhia frente ao risco de favorecimento do controlador.

16. Este Colegiado já esclareceu, a propósito, que *"as operações entre controlador e controlada colocam um ônus muito maior sobre os administradores envolvidos, (...) Todo o cuidado e diligência que se exige dos administradores em condições normais deve ser redobrado em negócios entre partes relacionadas, (...)"*².

17. Dada a natureza eminentemente procedimental desse dever, a conduta dos administradores se presta perfeitamente ao tipo de escrutínio levado a cabo pela SEP nos autos deste processo, que, como visto, centra-se no modo de condução da negociação que antecedeu à contratação. Incumbe então à CVM avaliar as medidas adotadas pelos administradores para assegurar o equilíbrio da operação, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto – em especial a relevância do negócio para a companhia e o tempo de que dispunham os administradores para tomar a decisão.

18. De outra parte, em consonância com o disposto no art. 117, §1º, alínea "f", o controlador não pode abusar de sua autoridade sobre a administração para contratar com a companhia em condições não equitativas. Extrai-se do texto normativo que a análise da CVM, neste caso, há de ser substancial, configurando-se o abuso apenas mediante a demonstração de que a transação foi lesiva para a companhia³. Ainda que o processo de negociação que levou à contratação não tenha sido conduzido a contento, o controlador deve ser responsabilizado apenas se restar comprovado que os termos do contrato o favoreceram em detrimento da companhia.

19. A isso se poderia objetar que seria mais justo tratar o controlador do mesmo modo que os administradores, tendo em vista a influência que ele é capaz de exercer na condução dos negócios da companhia. Nessa direção, poderia aventar-se a possibilidade de responsabilizá-lo por eventuais falhas verificadas no processo de negociação, com base no parágrafo único do art. 116, sob a alegação de que se trata de modalidade de abuso diversa daquela prevista no art. 117, §1º, alínea "f".

20. Tal posição, contudo, não me parece correta, uma vez que confunde perigosamente as funções desempenhadas pelos administradores com aquelas do controlador. Isto porque, no regime jurídico adotado pela Lei nº 6.404/1976, compete à administração, e em particular à diretoria, conduzir o processo de negociação que precede a contratação, em nome da companhia, com terceiros. E por isso mesmo, caso sejam identificadas falhas nesse processo, cumpre aos administradores, nos limites de suas atribuições, responder pelas consequências daí decorrentes.

21. Ademais, a responsabilização do controlador teria o efeito indesejável de incentivá-lo a intervir nas negociações realizadas pela companhia, pois, sendo responsável, é mesmo de se esperar que tenha participação ativa nesse processo.

22. Parece-me, portanto, que se estaria dessa maneira caminhando na contramão das melhores práticas de mercado, estimulando-se a interferência do controlador na contratação com sociedade integrante do mesmo grupo econômico, quando o mais adequado, do ponto de vista da governança, é que se abstenha de qualquer ingerência, permitindo que a administração conduza a operação com plena independência.

23. É em vista disso que me parece especialmente importante que a CVM delimite, com clareza, os deveres e responsabilidades que tocam ao controlador, de modo a evidenciar que a condução do processo de negociação compete aos administradores,

que não podem eximir-se do dever de zelar pela equidade da operação realizada com sociedade do mesmo grupo econômico, nem mesmo sob a alegação de que agiram sob a direção do controlador.

24. Voltando ao caso ora em análise, entendo, por tudo quanto dito acima, que a configuração do abuso de poder de controle depende da comprovação de que a alienação da participação na Projeto Rio não tenha sido realizada no melhor interesse da Companhia ou que tenha se dado em condições não equitativas, que favoreceram à PMV.

25. Quanto ao primeiro ponto, observo que a acusação, em momento algum, contestou a decisão da administração de vender a participação da Companhia na Projeto Rio durante o exercício de 2009, antes que o Empreendimento Ventura estivesse concluído. Vale notar que o processo de negociação foi deflagrado ainda no primeiro semestre de 2008, o que, como a própria SEP reconhece, afasta qualquer suposição de que existia, desde o início, o intuito de realizar a venda com o controlador.

26. Quanto ao segundo ponto, cumpre observar, inicialmente, que o desequilíbrio contratual é, usualmente, determinado por meio da comparação com outros negócios similares praticados no mercado ou com outro, hipotético, a ser celebrado com terceiro independente⁴. Nesse tocante, mostram-se plenamente aplicáveis os dois critérios estabelecidos no art. 156, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 para o contrato firmado com administrador, de acordo com os quais as condições contratuais devem ser *"idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros"*⁵.

27. No presente caso, compulsando os autos, não encontro elementos de prova suficientes para concluir que a cessão da participação da Companhia na Projeto Rio não tenha observado os padrões de mercado.

28. O único indício de desequilíbrio de que se dispõe é o fato de o Empreendimento Ventura ter sido alienado, em sua totalidade, a terceiros, pelo valor de R\$680 milhões, oito meses depois de sua aquisição pela BTS, o que representa uma valorização de 38% em relação ao preço pago à Companhia.

29. Posto que significativo, tal indício, tomado isoladamente, não se mostra conclusivo, já que a diferença entre os preços pode ser explicada por outras razões, em particular, pela evolução das condições do mercado imobiliário brasileiro. Nesse ponto, a própria SEP observa que os valores *"não devem ser interpretados como indicação definitiva do prejuízo à CCDI ou do favorecimento do acionista controlador. De fato, diversos outros fatores plausíveis e legítimos podem ter concorrido para explicar a diferença de preços entre os dois negócios"*.

30. A defesa, por sua vez, menciona estudos de firma de consultoria do ramo imobiliário de acordo com os quais as condições do mercado no início do segundo semestre de 2010 – quando ocorreu a venda do Empreendimento por R\$ 680 milhões – eram sensivelmente melhores do que aquelas observadas no segundo semestre de 2009 – quando a Companhia realizou a venda com a BTS (fls. 1.550-1.554).

31. A defesa destaca, adicionalmente, que, em dezembro de 2009, apenas 50% das obras estavam concluídas. Já em agosto de 2010, as obras estavam integralmente concluídas e já haviam sido celebrados contratos de locação para mais de 50% da área útil do edifício. Isso também poderia explicar a diferença entre os preços.

32. Convém notar, ademais, que, de acordo com informação disponível nos autos, na mesma época da venda realizada com a BTS, empreendimento imobiliário semelhante denominado "Torre Almirante", também padrão "AAA" e situado no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, fora alienado por valor correspondente a R\$ 8.977/m², inferior àquele recebido pela Companhia, equivalente a R\$ 12.812/m² (fls. 1.033-1.034).

33. Tampouco me parece possível afirmar, com base nos elementos trazidos aos autos, que a companhia teria contratado com terceiros em melhores condições. É fato – do qual, a meu ver, nem a acusação discorda – que a proposta apresentada pela PMV era mais vantajosa do que as demais recebidas pela administração da Companhia. Era superior não somente em termos financeiros, considerando o valor por metro quadrado, mas também porque não estava condicionada à anuência da sócia da Companhia na Projeto Rio, bem como não sujeitava o pagamento do preço à realização de *due diligence* ou ao implemento de outras condições, como a conclusão da obra ou a locação do imóvel a terceiro.

34. O que a acusação alega é que, no cumprimento de seus deveres legais, a administração da Companhia deveria ter prosseguido na negociação com os demais interessados na aquisição do ativo, de modo a conceder-lhes a oportunidade de superar a proposta formulada pela PMV. Ainda que se admita o acerto desse entendimento, é forçoso reconhecer que se trataria apenas de uma indicação de que teria sido *possível* obter condições contratuais melhores do que aquelas ofertadas pela PMV. A partir dessa suposição, contudo, não seria possível inferir, com o grau de certeza que se exige do julgador no processo administrativo sancionador, que a Companhia contratou com a BTS em condições diferentes daquelas que teriam prevalecido caso o negócio tivesse sido concluído com terceiro independente.

35. Nessa direção, antes de formulado o termo de acusação, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM já havia advertido que "(...) a suposição, apresentada pela SEP, no sentido de que se fosse oferecida, aos demais concorrentes, a possibilidade de apresentação de contrapropostas, o valor poderia ter sido melhor, s.m.j., não justifica a conclusão alcançada no sentido da inexistência da comutatividade na operação" (fl. 1277).

36. Em suma, são por essas razões que concluo que a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a PMV contratou com a CCDI em condições de favorecimento. Voto, portanto, pela absolvição da Participações Morro Vermelho S.A. da imputação de suposta infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea "f", da Lei nº 6.404/1976.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ V., nessa direção, o PAS CVM nº RJ2002/1173, Rel. Dir. Norma Parente, voto condutor Dir. Luiz Antonio Campos, julgado em 02.10.2003; e o PAS CVM nº 25/2003, Rel. Dir. Eli Loria, voto condutor da Pres. Maria Helena Santana, julgado em 25.3.2008.

² Voto condutor da Pres. Maria Helena Santana, PAS CVM nº 25/2003, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 25.3.2008.

³ Como, aliás, amplamente reconhecida na doutrina pátria. V., por todos, Nelson Eizirik, *A Lei das S/A Comentada*, vol. 4, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2ª ed., p. 249.

⁴ V. novamente Nelson Eizirik, *A Lei das S/A Comentada*, vol. 4, cit., 2015, p. 250-251.

⁵ Como já observado: “o §1º do art. 156 estabelece a necessidade de comutatividade (condições razoáveis e equitativas) e liga-a não só às condições de mercado, mas também às condições em que a companhia contrataria com terceiros. Estabelece, portanto, critérios semelhantes ao *entire fairness* (justiça integral) ou o *intrinsic fairness* (justiça intrínseca)” (Voto do Relator-Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, PAS CVM nº RJ2005/1443, julgado em 10.5.2006).

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/11199 realizada no dia 22 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/11199 realizada no dia 22 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, Senhor Presidente.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/11199 realizada no dia 22 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela absolvição da companhia Participações Morro Vermelho S.A., nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que, com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, a CVM não mais interporá recurso de ofício da decisão absolutória, que transita em julgado na primeira instância.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE